

INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE D. RICARDO ALVIRA BAEZA EN MATERIA DE HONORARIOS PROFESIONALES

I. Antecedentes:

El martes 8 de febrero de 2022 se ha recibido una solicitud del Gabinete del SEEAE de realizar un informe sobre el fondo de la cuestión planteada por D. Ricardo Alvira Baeza para su remisión a la Audiencia Nacional, que ha reclamado el expediente administrativo. El informe se solicita para el jueves 10 de febrero.

Este asunto tiene su origen en una solicitud de D. Ricardo Alvira Baeza del 23/3/2021 a la Ministra de Trabajo y Economía Social para que promoviera el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos profesionales. El Ministerio de Trabajo y Economía Social remitió esta solicitud a la SGT de MINECO el 29/3/2021 por tratarse de un asunto relacionado con la actividad profesional y no con el ámbito laboral.

El 12/10/2021 D. Ricardo Alvira Baeza interpuso un recurso contencioso-administrativo por falta de resolución del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre su solicitud, y la Audiencia Nacional ha solicitado el 12 de enero de 2022 a MINECO que le remita el expediente administrativo sobre esta cuestión. La SGT de MINECO trasladó el 7 de febrero de 2022 esta petición de la Audiencia Nacional al Gabinete del SEEAE, que ha solicitado un informe sobre el fondo del asunto.

II. Exposición de la solicitud:

D. Ricardo Alvira Baeza considera que la actual prohibición de honorarios mínimos profesionales es anticonstitucional y vulnera la legislación básica y la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea.

Por ello, solicita un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la situación actual y su modificación, derogando el artículo 5.Cinco.º de la Ley 7/1997 de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, y otorgando a los Colegios Profesionales la competencia para fijar honorarios mínimos o estableciéndolos mediante legislación nacional a efecto.

Los motivos por los que considera que la situación actual no es ajustada a derecho son los siguientes:

- En primer lugar, la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales modificó el párrafo 5 del artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales para establecer que éstos podrán establecer baremos de honorarios de carácter meramente orientativo, pero no honorarios mínimos.

Sin embargo, esta eliminación no ha sido proporcional a los objetivos buscados, que es una exigencia de la Directiva del test de proporcionalidad.

En particular, no se entiende por qué se pretende introducir más competencia en un mercado atomizado en



el que los profesionales carecen de fuerza para imponer sus intereses a sus clientes (el Estado y las grandes empresas).

- En segundo lugar, la prohibición de honorarios mínimos profesionales sitúa a los profesionales en una situación de inferioridad frente a los trabajadores asalariados, para los que se fija un SMI, por una mera cuestión coyuntural: el tipo de contrato bajo el cual realizan su actividad.

El artículo 14 de la Constitución Española prohíbe que se dé un tratamiento desigual a quienes se encuentren en situaciones esencialmente similares, por lo que la Ley 7/1997 vulnera dicho artículo.

- En tercer lugar, el salario mínimo interprofesional se introduce para proporcionar una remuneración suficiente a los trabajadores, tal y como se señala en la Constitución Española (artículo 35), en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 27.2, en el que se precisa que es inembargable) y en el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

III. Observaciones de la DGPOLECO

No se comparten los argumentos planteados por D. Ricardo Alvira Baeza y por tanto se considera que ha de desestimarse su solicitud.

- Como cuestión preliminar, y sin ánimo de entrar en un debate en materia constitucional que no compete a esta Dirección General, cabe recordar que el artículo 38 de la Constitución Española consagra el derecho a la libertad de empresa.

El Tribunal Constitucional (STC 83/1984, de 24 de junio) ha señalado que la libertad de empresa constituye una garantía del inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial “en libertad” y conlleva “el reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no solo para crear empresas y, por tanto, para actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado”.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que la defensa de la competencia constituye un presupuesto y un límite a libertad de empresa (SSTC 1/1982, 88/1986, 208/1999, de 11 de noviembre y 71/2012, de 16 de abril), y una defensa de aquella (STC 71/2012, de 16 de abril).

La incorporación de España a la Unión Europea ha supuesto un importante refuerzo de la libertad de empresa con la asunción de la libertad de movimiento de personas, bienes, servicios y capitales, y del acervo comunitario en materia de competencia.

- Se considera conveniente recordar la evolución de la normativa sobre Colegios Profesionales a lo largo de los últimos años.

Como bien señala el solicitante, la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales eliminó la regulación de los honorarios mínimos de las profesiones como función de los Colegios Profesionales y admitió que éstos pudieran establecer tan solo baremos de carácter meramente orientativo.

Pero, además, la normativa de los Colegios Profesionales se ha modificado también con posterioridad para adaptarla a la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE). En particular, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio introdujo múltiples modificaciones en la Ley de Colegios Profesionales. Entre otras muchas: estableció que los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; e introdujo la prohibición de que los Colegios



Profesionales puedan establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales (con la única excepción de la elaboración de criterios orientativos para la tasación de costas y la jura de cuentas de los abogados).

- Estas modificaciones tienen una racionalidad económica muy clara que la entonces Comisión Nacional de la Competencia explicó en su momento.

En su "Informe sobre el sector de servicios profesionales y Colegios Profesionales"¹ señala lo siguiente (p.42-43):

"(...) la fijación de tarifas orientativas es lo que en términos de derecho de la competencia se entiende por "prácticas conscientemente paralelas", con efectos finales similares a la fijación de precios. No se llega a establecer un cártel, pero los partícipes se comportan todos de la misma forma, porque pueden razonablemente anticipar cuál va a ser el comportamiento de sus competidores.

En efecto, las recomendaciones de precios no sólo presentan ventajas extremadamente dudosas, sino que son susceptibles de reforzar las posibilidades de coordinación de precios entre las empresas instaladas en el mercado.

La Comisión Europea se ha hecho eco en varias ocasiones de este enfoque. Así, en la Decisión 2005/8 de la Comisión Europea, por la que se condenó al Colegio de Arquitectos Belgas por la inclusión en sus normas deontológicas de baremos indicativos se afirmaba que:

(78) Conviene recordar, a título preliminar, la jurisprudencia constante según la cual la fijación de un precio, incluso si es simplemente indicativo o recomendado, afecta al juego de la competencia por el hecho de que permite a todos los participantes prever con un grado razonable de certidumbre cual será la política de precios que seguirán sus competidores, sobre todo si a las disposiciones relativas a los precios indicativos se une la posibilidad de controles y sanciones.

(99) La Comisión considera que el establecimiento del baremo (recomendado) de honorarios mínimos no puede ser considerado como necesario para garantizar el buen ejercicio de la profesión de arquitecto. El Colegio hace notar que el baremo puede servir de baremo indicativo en casos de demandas ante los Tribunales. Por el contrario, la Comisión estima que existen otras soluciones para comunicar informaciones sobre precios. Así, publicaciones recogidas por organizaciones independientes, tales como organizaciones de consumidores, o informaciones basadas en sondeos, pueden constituir una referencia más fiable para los consumidores y acarrear menos distorsiones a la competencia."

A su vez, en el "Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios"² se manifiesta lo siguiente (p. 66):

"Los honorarios, como se suele denominar al precio de los servicios profesionales, tienen un gran interés desde el punto de vista de la competencia. La libre fijación de precios, aspecto crucial para el correcto funcionamiento de la economía de mercado, debe ser la regla general para permitir que el sistema económico en general y los consumidores y usuarios en particular, obtengan los máximos beneficios de la competencia, al tiempo que se consigue la mejor asignación posible de los recursos productivos al señalar los precios relativos las necesidades o excesos existentes."

"La libertad de precios da lugar a una intensificación de la competencia que fomenta la innovación y las mejoras en la calidad y variedad de los servicios prestados, así como una mejor asignación de recursos productivos que refuerza el crecimiento económico y la creación de empleo. Por el contrario, las tarifas fijas, mínimas, máximas u orientativas, además de restringir la capacidad de obtener los anteriores beneficios,

¹ https://www.cnmc.es/sites/default/files/1254639_7.pdf

² https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186019_7.pdf



privilegian injustificadamente a los profesionales ya instalados, en detrimento de los nuevos entrantes, lo que afecta especialmente a los profesionales jóvenes y a aquellos más emprendedores."

"La fijación de honorarios es una de las prácticas más dañinas de la competencia, puesto que limita la capacidad de los profesionales de utilizar el precio como herramienta de diferenciación y competencia. Los honorarios fijos o mínimos, junto a la restricción de la oferta, llevan a que los precios se sitúen por encima de lo que resultaría de la libertad de oferta y demanda, con el consiguiente perjuicio para consumidores. Los baremos orientativos de honorarios y los honorarios máximos, aunque puedan no ser vinculantes, favorecen el alineamiento de tarifas, y la experiencia muestra que normalmente se combinan con otros elementos que aumentan su grado de vinculación para el profesional. Además, en general, independientemente del grado de obligatoriedad que supongan los honorarios acordados, el proceso que lleva a su establecimiento implica compartir información sobre costes y otras cuestiones comercialmente sensibles entre competidores, lo que en sí mismo puede suponer una restricción de la competencia perseguible por la LDC."

En este informe se detallan también otras prácticas restrictivas de la competencia ejercidas por los Colegios Profesionales.

- Cabría añadir que no se comparte el planteamiento según el cual la legislación da un tratamiento distinto en situaciones sustancialmente iguales. El profesional realiza una actividad mercantil y el trabajador una actividad laboral, lo que constituyen marcos de actividad que presentan diferencias sustanciales en cuanto a libertad de actuación y asunción de riesgo en materia retributiva, entre otros aspectos. Tampoco se considera apropiado equiparar a todos los efectos el precio que una empresa cobra a sus clientes por sus servicios (clientes que no solo son el Estado o una gran empresa, como señala el solicitante, sino también multitud de particulares) con el salario que cobra un empleado.
- En definitiva, se considera que la actual regulación de los honorarios de los profesionales se ajusta al principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución, a la normativa comunitaria y nacional en materia de defensa de la competencia y libertad de prestación de servicios, y que tiene todo el sentido económico.